DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 17-2022-LGP-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje de Emergencia.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Ares.

Demandado : Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco.

ARBITRO DE EMERGENCIA : Abg. Luis Puglianini Guerra.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

PEDIDO CAUTELAR : Medida Cautelar de No Innovar

INICIO DE LA SOLICITUD : 21 de octubre de 2022.

FECHA DE CONCLUSION : 07 de noviembre de 2022.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Arbitraje N° 17-2022-LPG-CA-CECARD/AYA

Consorcio Ares
(en adelante, el Contratista o el Consorcio)

vs.

Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco
(en adelante, la Entidad o la Municipalidad)

RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE EMERGENCIA

Árbitro Único
Luis Puglianini Guerra

EXP. N° 17-2022-LPG-CA-CECARD/AYA

Ayacucho, 07 de noviembre del 2022.

DEMANDANTE: **CONSORCIO ARES**
DEMANDADO: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO**

RESOLUCIÓN CAUTELAR N° 04

VISTOS:

a. Escrito de fecha 21 de octubre de 2022 presentado por el CONSORCIO, con sumilla "SOLICITAMOS ARBITRAJE DE EMERGENCIA Y PEDIMOS TUTELA CAUTELAR".

b. Escrito de fecha 26 de octubre de 2022, presentado por la MUNICIPALIDAD, con sumilla "Absuelvo traslado".

c. Escrito de fecha 27 de octubre de 2022, con sumilla "amplío fundamentos de la petición cautelar y amplio futuras pretensiones", presentado por el CONSORCIO.

d. Escrito de fecha 03 de noviembre de 2022, presentado por la MUNICIPALIDAD con sumilla "Absuelve traslado".

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

ATENDIENDO:

PRIMERO: Mediante escrito del 21 de octubre de 2022, el Consorcio solicitó al Centro de Arbitraje el inicio de un arbitraje de emergencia y la emisión de una medida cautelar.

SEGUNDO: El pedido cautelar del Consorcio consiste en lo siguiente:

> ***ORDENAR*** *A la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO* ***SE ABSTENGA A EJECUTAR****:*
>
> *(i) La* ***CARTA FIANZA N° 216301224-R31****, emitida por INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, por el importe de S/. 1´313,323.25 (un millón trecientos trece mil trecientos veintitrés con 25/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP.*
>
> *(ii) Solicitamos además que los efectos de la orden cautelar se extiendan a INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con domicilio en Av. Felipe Pardo y Aliaga 699 - oficina 302 – San Isidro – Lima;* ***ORDENANDO*** *se abstenga y/o rechace cualquier requerimiento y/o solicitud por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO destinada a ejecutar La* ***CARTA FIANZA N° 216301224-R31****.*

En consecuencia, se curse oficio a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO, con domicilio procesal en la Av. Huanta S/N, distrito de Ayna – San Francisco; así como a INSUR COMPANIA DE SEGUROS, con sede en Av. Pardo y Aliaga Nº 699, oficina Nº 302, San Isidro – Lima.

TERCERO: Asimismo, mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2022, el Consorcio amplio los fundamentos de su solicitud cautelar.

CUARTO: El Árbitro Único pese al pedido formulado para que la medida cautelar sea dictada sin conocimiento de la parte contraria *-in audita altera pars-*, en salvaguarda del derecho de contradicción de la Entidad no encontrando fundamento y prueba algún que permita evidenciar la necesidad de no poner en conocimiento a la otra parte y que ello afectaría el efecto de la medida, por lo que el Árbitro Único decidió conferir traslado del pedido cautelar; la Entidad absolvió el pedido cautelar y la ampliación a sus fundamentos mediante escritos de fecha 26 de octubre de 2022 y 3 de noviembre de 2022, respectivamente.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, las facultades de los árbitros para dictar medidas cautelares se encuentran expresamente señaladas en una norma con rango de Ley, como es el Decreto Legislativo N° 1071, más específicamente en el Artículo 47° del citado texto legal;

Segundo: Que, el numeral 1) del artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1071 establece que: "*Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida*".

Tercero: Que, asimismo, en este caso resulta aplicable los reglamentos de arbitraje del Centro, donde se incluye la posibilidad de solicitar un arbitraje de emergencia para pedir una medida cautelar previa a constitución del Tribunal Arbitral que conocerá el fondo del arbitraje.

Cuarto: Que, de lo argumentado por el Consorcio, se observa que la medida pretendida se refiere, tal como se ha mencionado en los antecedentes, en disponer que se ordene a la Entidad que se abstenga de ejecutar la **CARTA FIANZA N° 216301224-R31**, emitida por INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, por el importe de S/. 1´313,323.25 (un millón trecientos trece mil trecientos veintitrés con 25/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N° 091-2016-

MDASF/ULCP, lo cual es concordante con lo establecido en el literal a) del numeral 2) del artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1071.

Quinto: Que, el Consorcio fundamenta la solicitud de su medida cautelar en:

Nuestra pretensión cautelar se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 63° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje – CECARD, que señala:

> *"Artículo 63°. – Medida cautelar emitida por Árbitro de Emergencia*
> *1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiere medida cautelar urgente puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud.*
> *2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora. (…)"*

Asimismo, nuestra pretensión cautelar se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 47° del Decreto Legislativo 1071, que señala:

> *"1. Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida.*
> *2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordena a una de las partes:*
> *a. Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la controversia;*
> *b. Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral;*
> *c. Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente; o*
> *d. Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia."*

1. PRETENSIONES DE LA FUTURA DEMANDA ARBITRAL

Siendo que, la petición cautelar invocada tiene una naturaleza extra procesal, y además, en nuestro sistema jurídico las medidas cautelares tienen

un carácter instrumental; es necesario señalar que se iniciara un proceso arbitral que tendrá como objeto las siguientes pretensiones:

2. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que el Tribunal Arbitral ***DECLARE LA INEFICACIA*** *de la Resolución del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP, efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO, contenida en la Resolución de Alcaldía N° 188-2020-MDASF/A de fecha 14 de setiembre de 2020, notificada mediante la Carta Notarial S/N de fecha 14 de setiembre de 2020.*

3. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que el Tribunal Arbitral ORDENE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO asumir los gastos que irrogue la organización y tramitación del arbitraje, incluyendo los honorarios arbitrales, gastos administrativos, así como la asesoría técnica y legal.

4. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL

De conformidad con la Clausula Décimo Novena: Solución de Controversias del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP, se ha señalado:

"Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación y arbitraje, según acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en el (…) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo INSTITUCIONAL."

5. FUNDAMENTOS DEL PEDIDO CAUTELAR

ANTECEDENTES

5.1. *Con fecha 27 de setiembre de 2016, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO y el Consorcio Ares (en adelante el CONSORCIO), suscribieron el Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP para el "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARUCHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AURORA, DISTRITO DE AYNA – LA MAR – AYACUCHO", derivado de la Licitación Pública N° 003-2016-MDASF/CS.*

5.2. *Culminando el plazo de ejecución de la obra, y de conformidad con lo establecido en el artículo 178° del Reglamento de la Ley de*

Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 350-2015-EF) vigente a la fecha de ocurridos los hechos, se ha realizado la anotación en el asiento 789 del cuaderno de obra, la culminación de todas las partidas de la obra.

5.3. Por esta razón, con fecha 25 de febrero de 2019 se procedió a la verificación de la obra, habiéndose suscrito el Acta de Pliego de Observaciones.

*5.4. Consecuentemente, en el **asiento 791 del cuaderno de obra, fechado el 12 de abril de 2019**, se ha **ANOTADO EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES** por parte del CONSORCIO; consecuentemente se solicita al Supervisor informar a la ENTIDAD; por lo que, se debió seguir con el procedimiento de recepción de obra establecido en el artículo 178° del RLCE.*

5.5. Posteriormente, a través de la Carta Notarial de fecha 15 de setiembre de 2020, a la cual se adjunta la Resolución de Alcaldía N° 188-2020-MDASF/A 14 de setiembre de 2020, la ENTIDAD nos comunica su decisión de resolver el Contrato por la causal de incumplimiento de contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 135°.1 del RLCE; señalando que el CONSORCIO no habría cumplido con levantar el pliego de observaciones.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RESOLVER el CONTRATO N°091-2016-MDASF/ULCP, de fecha 27 de setiembre del 2016, suscrito entre el CONSORCIO "ARES" y el Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco, servicio de ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de San Francisco y los Centros Poblados de Ahuarochayocc, Carmen Pampa, Las Palmas y Aurora, Distrito de Ayna – La Mar – Ayacucho", por las causales de incumplimiento de contrato, en aplicación del numeral 1 del artículo 135° y del artículo 136° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF.

SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

5.6. Con respecto a la recepción de la obra y el levantamiento de las observaciones, el artículo 178° del RLCE señala:

> *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informa a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe.*

(…)

2. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.

(…)

3. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad debe pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo.

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse.

4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del día siguiente de la mencionada notificación la Entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el tercer párrafo del artículo 174."

5.7. Entonces, podemos comprender que, dentro del procedimiento de recepción de obra, no se puede fundar una resolución del contrato por falta de absolución de dichas observaciones. Esto, por cuanto el mismo artículo 178° del RLCE señala que, ante la inconformidad de alguna de las partes, sobre la absolución de las observaciones, o "de persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse".

E incluso, ante la ausencia de trabajos realizados por el contratista, en el 50% del plazo otorgado para la subsanación de las observaciones, el RLCE no prevé una resolución de contrato como mecanismo.

Por esta razón, señalamos que la Resolución del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP efectuada por la ENTIDAD, y notificada mediante Carta Notarial S/N de fecha 14 de setiembre de 2020, no tiene un sustento jurídico, y por lo tanto, se debe declara su ineficacia o invalidez.

5.8. Asimismo, es necesario recordar que el levantamiento de las observaciones por parte del CONTRATISTA fue anotado en el Asiento 791 del Cuaderno de Obra, con fecha 12 de abril 2019; ante lo cual, se debió seguir el procedimiento establecido en el citado artículo 178° del RLCE, esto es, la comunicación por parte del SUPERVISOR a la ENTIDAD, la evaluación por parte del comité de recepción y el pronunciamiento de la misma ENTIDA.

5.9. Adicionalmente, conforme lo señala el citado artículo 178° del RCLE, ante el incumplimiento en el levantamiento de las observaciones por parte del CONTRATISTA, se prevé un procedimiento (que no es el de resolución contractual), en el cual, el SUPERVISOR (ante la falta de inicio de actividades en el transcurso del 50% del tiempo otorgado), informa de inmediato a la ENTIDAD, quien da por vencido el plazo y notifica (esta decisión) al CONTRATISTA.

Es en este caso que, la ENTIDAD asume la subsanación e las observaciones.
Sin embargo, este procedimiento, tampoco fue realizado por la ENTIDAD, pues no existe ninguna notificación mediante la cual se de por vencido el plazo otorgado para la subsanación, ni mucho menos anotaciones por parte del SUPERVISOR que establezcan una inactividad por parte del CONTRATISTA durante el 50% del tiempo otorgado para la subsanación.

SOBRE EL FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO

5.10. Con respecto a las causales de resolución de contrato, estas fueron establecidas en el artículo 135° del RLCE que señala:

"La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo136.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato."

5.11. Por otro lado, el artículo 136° del mismo RLCE establece el procedimiento que se debe observar para resolver el contrato:

"Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato."

5.12. Por lo tanto, se tiene que, ante el incumplimiento de alguna obligación (contractual, legal o reglamentaria) por parte del CONTRATISTA, la ENTIDAD debe realizar un requerimiento previo, en el cual se establezca de forma inequívoca la obligación cuyo cumplimiento se exige, el

otorgamiento de un plazo (que en el caso de ejecuciones de obras no será menor a 15 días) para cumplir la obligación, y además, apercibiendo la resolución del contrato.

Entonces, el incumplimiento de obligaciones puede ser fundamento suficiente para la resolución de un contrato, siempre que, ***en efecto se hubiera incumplido una obligación*** *y* ***se observe el procedimiento establecido en el artículo 136° del RCLE;*** *lo que, en el presente caso no se ha cumplido.*

5.13. La Resolución del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP, que se encuentra materializada mediate la Resolución de Alcaldía N° 188-2020-MDASF/A de fecha 14 de setiembre de 2020, se ha señalado:

> **SE RESUELVE:**
>
> *Artículo Primero.- RESOLVER el CONTRATO N°091-2016-MDASF/ULCP, de fecha 27 de setiembre del 2016, suscrito entre el CONSORCIO "ARES" y el Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco, servicio de ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de San Francisco y los Centros Poblados de Ahuarochayocc, Carmen Pampa, Las Palmas y Aurora, Distrito de Ayna – La Mar – Ayacucho", por las causales de incumplimiento de contrato, en aplicación del numeral 1 del artículo 135° y del artículo 136° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF.*

Es decir, la ENTIDAD utiliza como fundamento el incumplimiento de obligaciones. Sin embargo, como ya se ha señalado, esta causal de resolución de contrato, que se encuentra establecida en el artículo 135° del RLCE, debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 136° del mismo RLCE; esto es, la realización de un requerimiento previo, con un plazo no menor de 15 días, y bajo apercibimiento de resolver el contrato.

5.14. Asimismo, es necesario recordar que, el levantamiento de las observaciones fue anotadas en el Asiento 791 del Cuaderno de Obra, que está fechada el 12 de abril de 2019; es decir, ***la obligación de levantar las observaciones fue efectuadas****. Entonces, ante esta anotación, nuevamente se debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 178° del RLCE, esto es, la comunicación del SUPERVISOR a la ENTIDAD sobre el levantamiento de las observaciones, la evaluación del comité de recepción y el pronunciamiento de la ENTIDAD.*

Sin embargo, la ENTIDAD utiliza como fundamento el incumplimiento de obligaciones, cuando, de existir algún incumplimiento, este solo se podría conocer después de haber culminado el procedimiento establecido en el tantas veces citado artículo 178° del RLCE.

6. *FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PEDIDO CAUTELAR VEROSIMILITUD DEL DERECHO*

6.1. *La verosimilitud del derecho o fumus boni iuri comprende la apariencia certidumbre que reviste el derecho invocado y que será materia de un pronunciamiento definitivo, cuya ejecución debe ser salvaguardada.*

La verosimilitud del derecho, en las medidas cautelares de no innovar, se vinculan al ámbito de lo hipotético y lo razonablemente posible; esto es, un nivel de cognición de posibilidad más que de probabilidad.

6.2. *En este sentido, se tiene que* ***el derecho que se invoca*** *es que* ***LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 091-2016-MDASF/ULCP*** *(efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO, contenida en la Resolución de Alcaldía N° 188-2020-MDASF/A de fecha 14 de setiembre de 2020),* ***NO SE HA EFECTUADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 135° Y 136° DEL RLCE, esto es, no es acorde a derecho, y por lo tanto, no debe generar efectos jurídicos****.*

6.3. *En el caso en particular, la Resolución del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP, tiene como fundamento el incumplimiento de obligaciones por parte del CONTRATISTA.*

Al respecto, esta causal de resolución del contrato, que se encuentra establecida en el artículo 135° del RLCE, requiere para su configuración, la existencia de un requerimiento previo, mediante el cual se exija el cumplimiento de la obligación, en el plazo de 15 días y bajo apercibimiento de resolver el contrato, lo que ***no ha sucedido en el presente caso, por lo que, la Resolución del Contrato efectuada por la ENTIDAD contraviene el RLCE.***

Por otro lado, la Resolución del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP, efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO, se ***encuentra contenida en la Resolución de Alcaldía N° 188-2020-MDASF/A de fecha 14 de setiembre de 2020****, y fue notificada mediante Carta Notarial S/N de fecha 15 de setiembre de 2020.*

Sin embargo, la obligación cuyo incumplimiento se imputa (esto es, la falta de levantamiento de observaciones) fue superada, pues mediante la anotación efectuada en el Asiento 791 de fecha 12 de abril de 2019 (que consta en el Cuaderno de Obra), el CONSORCIO (mediante el Residente de Obra) levanta las observaciones y solicita al SUPERVISOR proceda a informar a la ENTIDAD.

Ante esta anotación, se debió iniciar con el procedimiento establecido en el numeral 2 y 3 del artículo 178° del mismo RLCE, que establece:

"2. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituyen en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de Recepción de Obra.

3. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad debe pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo.

<u>De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse</u>."

Entonces, se tiene que, ante la anotación en el cuaderno de obra, es el SUPERVISOR quien tiene que iniciar el procedimiento ante la ENTIDAD, con la finalidad de verificar el levantamiento de las observaciones; lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues la ENTIDAD, lejos de constatar el levantamiento de las observaciones, notifica al CONSORCIO la Resolución de Alcaldía N° 188-2020-MDASF/A de fecha 14 de setiembre de 2020 mediante la cual resuelven el contrato.

6.4. Ahora bien, sobre las razones por las cuales la Resolución del Contrato efectuada por la ENTIDAD no debe generar efectos jurídicos (es decir, se

debe declarar su ineficacia); es necesario precisar que uno de estos efectos jurídicos es precisamente la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Es precisamente este efecto el que se busca evitar con la tutela cautelar que se solicita, pues al haberse resuelto el contrato sin observar los preceptos establecidos en el artículo 135°, 136° y 137° del RLCE, no debe generar efectos jurídicos.

6.5. *Además, es necesario precisar que la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, solamente puede ser efectuada cuando la Resolución del Contrato efectuada por la ENTIDAD quede consentida. En este mismo sentido el artículo 131° del RLCE señala:*

> *"2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado."*

En el presente caso, la Resolución del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP, efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO, nunca fue consentida, pues se ha iniciado un proceso arbitral ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho; el cual fue archivado por falta de pago.

PELIGRO EN LA DEMORA Y PERJUICIO IRREPARABLE

6.6. *Siendo que, la **CARTA FIANZA N° 216301224-R31**, emitida por INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, por el importe de S/. 1´313,323.25 (un millón trecientos trece mil trecientos veintitrés con 25/100 soles), tiene una naturaleza incondicional, irrevocable, indivisible y de realización automática; esta puede ser ejecutada por la ENTIDAD en cualquier momento. Por lo tanto, el peligro tiene como principal fundamento la posibilidad que tiene la ENTIDAD de ejecutar la CARTA FIANZA N° 216301224-R31, a pesar de que la resolución del contrato no sea acorde a derecho y a lo señalado en el RLCE, a pesar de no se encontrarse consentida, de que no exista un laudo arbitral que lo valide.*

Es necesario precisar también, que la doctrina nacional establece que el perjuicio invocado en las medidas cautelares de no innovar, exige un gado de posibilidad en su configuración; esto es, un peligro fundado y razonable, que no necesita ser cierto e inminente.

6.7. *Asimismo, de conformidad con el artículo 687° del Código Procesal Civil, "Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resuelve de aplicación otra vista en la ley."*

En este sentido, es necesario la configuración de un perjuicio irreparable y además inminente, que en el presente caso es concreto; pues, de conformidad con la Carta Notarial S/N de fecha 15 de octubre de 2022, la ENTIDAD ha requerido a INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS la ejecución de la CARTA FIANZA N° 216301224-R31; y, siendo esta fianza incondicional, es inminente su ejecución.

PROPORCIONALIDAD Y ADECUACIÓN DE LA MEDIDA

6.8. *La medida cautelar de no innovar tiene como objeto mantener la situación de hecho y de derecho de la CARTA FIANZA N° 216301224-R31 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP, mediante su no ejecución.*

Entonces, la finalidad que se busca salvaguardar es el patrimonio del CONSORCIO que se verá afectado ante la ejecución de la CARTA FIANZA N° 216301224-R31; y, el medio por el cual se pretende este resguardo, es mediante la medida cautelar de no innovar.

En este sentido, ***la medida cautelar de no innovar es la más adecuada****, pues busca mantener la situación de hecho y de derecho de la CARTA FIANZA N° 216301224-R31, con la finalidad de que esta no sea ejecutada y genere un perjuicio al CONSORCIO.*

Asimismo, ***no existe otra medida que cumpla esta finalidad****, pues la medida de no innovar es la única que, por su naturaleza, busca mantener el status de hecho y de derecho, hasta la emisión de una decisión que resuelva la controversia jurídica.*

Finalmente, realizando una ***ponderación*** *entre el derecho cuya tutela se busca, y el derecho de la ENTIDAD, esta última no se verá afectada, pues el pedido cautelar de no ejecutar la CARTA FIANZA N° 216301224-R31, comprende a su vez mantener la vigencia de estas; es decir, la ENTIDAD* ***no se vería afectada, pues seguiría teniendo afianzado o garantizado su derecho****.*

7. CONTRA CAUTELA

*7.1. A efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 60° y 64° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje - CECARD, ofrecemos **contracautela en la forma de Caución Juratoria de cuantía indeterminada**. Sin embargo, dejamos a criterio del Tribunal la decisión de exigir otra contracautela en la forma que estime adecuada.*

7.2. En lo que concierne a la reciente modificatoria al numeral 2 del artículo 8° de la Ley de Arbitraje por medio del Decreto de Urgencia No. 20-2020 (en adelante, el "DU 20- 2020"), incluyendo un segundo párrafo a dicho artículo, el cual establece que, en los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral precisándose que el monto de la garantía no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento, manifestamos lo siguiente:

i. A propósito del dictado del DU 20-2020, se tendría como exigencia normativa la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial por un monto no menor a la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, lo que implica que, en términos sencillos, la Entidad tendría una doble garantía y se estaría condicionando al Consorcio la concesión de la medida cautelar solicitada.

ii. El Tribunal Constitucional ha establecido que "(...) la igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2° de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: "[...] toda persona tiene derecho [...] a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, se está frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino en ser tratadas del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación"[1].

iii. Asimismo, el derecho a la igualdad tiene dos expresiones: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la ley debe ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de hecho de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión

[1] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 2835-2010-PA/TC, fundamento jurídico 38.

considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

iv. *Por lo que, **por mandato constitucional las normas deben ser aplicables por igual**, el solo hecho de que la Entidad, que es parte del Estado peruano, sea parte en una **relación contractual**, más allá de las prerrogativas que ya tiene por mandato de la Ley de Contrataciones del Estado, no implica que se tenga que admitir como válida una exigencia legal que desconoce el elemental principio de igualdad reconocido constitucionalmente.*

v. *De otro lado, como se puede apreciar de la Exposición de Motivos del DU 20-2020, se afirma que existe una "abusiva" utilización de las medidas cautelares por parte de los Consorcios, cuyo otorgamiento genera consecuencias negativas para el Estado, por ejemplo, paralización de la ejecución de obras, afectación en la prestación de servicios públicos, etc. En el presente caso, ninguna de las medidas cautelares solicitadas podría ser entendida como "abusiva", sino todo lo contrario, es la Entidad quien está actuando con total abuso y arbitrariedad hacia la empresa.*

En relación al derecho de la empresa a la tutela jurisdiccional efectiva, el Tribunal Constitucional ha establecido que "(...) la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia"[2].

En el presente caso, es fundamental que el Árbitro de emergencia tenga en consideración que esta solicitud de medida cautelar se realiza en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, que se encuentra reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política vigente, y que dicho derecho debe prevalecer por sobre una traba ilegal tal como la establecida por el DU 20-2020.

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 763-2005-PA/TC, fundamento jurídico 06.

*7.3. Por las razones expuestas, al vulnerarse derechos constitucionales tales como el de igualdad y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, rogamos al Árbitro de emergencia que, **en el marco del reconocimiento establecido en el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 142-2011-PA/TC**, hacer control difuso y establecer que no corresponde exigir para el caso concreto la fianza bancaria y/o patrimonial señalada en la norma que se inaplica (modificatoria al numeral 2 del artículo 8° de la Ley de Arbitraje por medio del DU 20-2020).*

Adicionalmente, Consorcio agregó fundamentos en su escrito del 27 de octubre de 2022, señalando lo siguiente:

1. ***FUTURAS PRETENSIONES QUE SERÁN MATERIA DEL PROCESO ARBITRAL***

   En el apartado 5 del escrito de petición cautelar se ha señalado las futuras pretensiones que serán materia del proceso arbitral, esto, pues la tutela cautelar que se pretende tiene una naturaleza extra procesal.

   En este sentido, precisamos que, a las futuras pretensiones señaladas en el apartado 5 del escrito de petición cautelar se le acumularan las siguientes:

   A. ***TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL***

   Que, el Tribunal Arbitral ORDENE a la ENTIDAD el pago de la Valorización N° 18 por el monto de S/. 226,646.82 (doscientos veinte seis mil seiscientos cuarenta y seis con 82/100 soles), correspondientes mayores metrados, a FAVOR del CONSORCIO ARES.

   B. ***CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL***

   Que, el Tribunal Arbitral ORDENE a la ENTIDAD el pago del reajuste de la valorización principal por el monto de S/. 248,602.12 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos dos con 12/100 soles)., a FAVOR del CONSORCIO ARES.

2. ***FUNDAMENTOS ADICIONALES DEL PEDIDO CAUTELAR***

   ANTECEDENTES

   2.1. Con fecha 27 de setiembre de 2016 la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO y el CONSORCIO ARES suscribieron el Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP para el "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARUCHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AURORA, DISTRITO DE AYNA – LA MAR – AYACUCHO".

   Culminando el plazo de ejecución de la obra, y de conformidad con lo establecido en el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 350-2015-EF) vigente a la fecha de ocurridos los hechos, se ha realizado la anotación en el asiento 789 del cuaderno de obra, la culminación de todas las partidas de la obra.

Por esta razón, con fecha 25 de febrero de 2019 se procedió a la verificación de la obra, habiéndose suscrito el Acta de Pliego de Observaciones.

2.2. *Consecuentemente, en el* ***asiento 791 del cuaderno de obra, fechado el 12 de abril de 2019,*** *se ha* ***ANOTADO EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES*** *por parte del CONSORCIO; consecuentemente se solicita al Supervisor informar a la ENTIDAD; por lo que, se debió seguir con el procedimiento de recepción de obra establecido en el artículo 178° del RLCE.*

Posteriormente, a través de la Carta Notarial de fecha 15 de setiembre de 2020, a la cual se adjunta la Resolución de Alcaldía N° 188-2020-MDASF/A 14 de setiembre de 2020, ***la ENTIDAD nos comunica su decisión de resolver el Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP*** *por la causal de incumplimiento de contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 135°.1 del RLCE; señalando que el CONSORCIO no habría cumplido con levantar el pliego de observaciones.*

SOBRE LA VALORIZACIÓN N° 18 (MAYORES METRADOS)

2.3. *Durante la ejecución de la obra "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARUCHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AURORA, DISTRITO DE AYNA – LA MAR – AYACUCHO", el CONSORCIO ARES ha realizado mayores metrados en la obra principal que fueron valorizadas de conformidad con el RLCE. Dicha* ***Valorización N° 18 asciende al monto de S/. 226,646.82 (doscientos veinte seis mil seiscientos cuarenta y seis con 82/100 soles).***

La referida Valorización N° 18 fue presentado mediante Carta N° 014-2019-CONSORCIO ARES/EJC-RL de fecha 04 de febrero de 2019, y recepcionada por el Supervisor de Obra el 05 de febrero de 2019.
Mediante Carta Notarial N° 025-2019-CONSORCIO ARES /EJE-RL de fecha 11 de diciembre de 2019, dirigida a la Municipalidad Distrital de Ayna – San Francisco se ha requerido el pago de la referida Valorización N° 18 correspondiente mayores metrados de la obra principal; requerimiento que no fue atendido por la ENTIDAD.

2.4. *Con respecto al pago de valorizaciones, de conformidad con el artículo 166° del RLCE, se señala:*

"Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.
(…)

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes (…).
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputable a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil."

En este sentido, y no habiéndose cuestionado la valorización N° 18 presentada por el CONSORCIO, este tiene el derecho de recibir el pago de S/. 226,646.82 (doscientos veinte seis mil seiscientos cuarenta y seis con 82/100 soles); así como, los intereses legales generados hasta la fecha del pago.

SOBRE LAS VALORIZACIONES DEL ADICIONAL N° 01, 02 Y 03

2.5. *En igual sentido que los fundamentos anteriores, durante de la ejecución de la obra "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARUCHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AURORA, DISTRITO DE AYNA – LA MAR – AYACUCHO", se han tramitado y aprobado los adicionales N° 01, N° 02 y N° 03 que ascienden a la suma de S/. 833,697.10 (ochocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y siete con 10/100 soles).*

Mediante Carta Notarial N° 025-2019-CONSORCIO ARES /EJE-RL de fecha 11 de diciembre de 2019, dirigida a la Municipalidad Distrital de Ayna – San Francisco se ha requerido el pago de la referida Valorizaciones del Adicional N° 01, 02 y 03; lo que si fue cumplido por la ENTIDAD; es decir, la ENTIDAD ha realizado el pago de S/. 833,697.10 (ochocientos treinta y tres mil seiscientos noventa y siete con 10/100 soles.

SOBRE EL PAGO DE REAJUSTES DE LA VALORIZACIÓN PRINCIPAL

2.6. *En la misma Carta Notarial N° 025-2019-CONSORCIO ARES /EJE-RL de fecha 11 de diciembre de 2019, el CONSORCIO también exige el pago de Reajustes de la* ***Valorización Principal, que asciende a la suma de S/. 248,602.12 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos dos con 12/100 soles).***

Dicho pago debe ser considerado como un saldo a favor del contratista, y que también debe ser pagado por la ENTIDAD.

SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Y LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

2.7. Con fecha 16 de setiembre de 2020, el CONSORCIO ARES ha iniciado un proceso arbitral ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y de la Producción de Ayacucho. Este proceso arbitral tiene como pretensión principal cuestionar la valides y eficacia de la resolución del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP, comunicada mediante la Carta Notarial S/N de fecha 15 de setiembre de 2020.

Por esta razón, la resolución del contrato no se ha consentido, pues el CONSORCIO ha iniciado un proceso arbitral dentro del plazo de 30 días hábiles contemplados en el párrafo tercero del artículo 137° del RLCE[3].

En este sentido, y en aplicación del artículo 179° del RLCE[4], que no se ha iniciado el procedimiento de liquidación de la obra.

2.8. Con respecto a la liquidación del contrato de obra, la OPINIÓN N° 023-2021/DTN señala:

> *"De acuerdo con el anexo N° 1 definiciones del Reglamento se entiende por liquidación del contrato como el "calculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que **<u>tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo económico</u>**" (…)*
> *En esa misma línea, SALINAS SEMINARIO define la liquidación de contrato de obra como proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicable al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, <u>el costo total de obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad</u>.*
> *Así, la liquidación del contrato de obra debe contener <u>todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación</u>, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. (…)"*

---

[3] **Artículo 137°. – Efectos de la resolución**
(…)
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesad a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.

[4] **Artículo 179°. – Liquidación del contrato de obra**
El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación cálculos detallados, dentro del plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
(…)
No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Adicionalmente, la OPINIÓN N° 023-2021/DTN también señala:

"(…) se debe tener presente cuál es la finalidad de la liquidación del contrato de obra. Como se anotó, con este procedimiento se busca determinar —principalmente— el costo total de la obra y la existencia de un saldo a favor o en contra del contratista o de la Entidad. (…)".

Entonces, se tiene que en la liquidación de obra se pondrá por un lado el costo total de la obra (hasta el momento de la resolución del contrato) y la existencia de saldo (o pagos) a favor o en contra del CONTRATISTA o de la ENTIDAD.

Esto se encuentra estrechamente relacionado con la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, de adelanto directo y de adelanto de materiales; pues, de existir saldo en contra del CONSORCIO (como, por ejemplo, la amortización de los adelantos, o el pago de penalidades), es natural que esto sea solventado por las garantías. A contrario sensu, si existe un saldo a favor del CONSORCIO, es también natural que las garantías sean devueltas; y además, es más que notorio que estas garantías deben mantenerse vigente hasta la liquidación de la obra, esto es, hasta que se dilucide la existencia de un saldo a favor o en contra del contratista o de la entidad.

Lo argumentado se encuentra fundamentado en lo establecido en el artículo 126° del RLCE que señala:

> *"Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente de diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en caso de bienes, servicios en general y consultoría en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en caso de ejecución y consultoría de obras.*
>
> *En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista, la Entidad debe devolver la garantía de fiel cumplimiento, aun cuando se someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor." [Lo subrayado es nuestro]*

SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

2.9. *Mediante la Carta S/N de fecha 15 de octubre 2022 la ENTIDAD ha requerido a INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, la ejecución de la Carta Fianza N° 216301224-R31, que garantiza el fiel cumplimiento del contrato.*

Al respecto, debe ser de aplicación lo señalado en el citado artículo 126° del RLCE que señala:

> *"Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente de diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta (…) el consentimiento de la liquidación final, en caso de ejecución y consultoría de obras.*
>
> > *En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista, la Entidad debe devolver la garantía de fiel cumplimiento, aun cuando se someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor."*

2.10. En primer lugar, se deben mantener vigentes las garantías hasta la realización de la liquidación de la obra, esto es, hasta que se establezca la existencia de un saldo a favor o en contra del CONSORCIO o de la ENTIDAD; solo así, se podrá dilucidar si la garantía contenida en la Carta Fianza N° 216301224-R31 debe ser o no ejecutada.

En segundo lugar, una vez realizada la liquidación, de existir saldo en contra del CONSORCIO, esta podrá ser solventada por las garantías; de lo contrario, de existir un saldo a favor del CONSORCIO, la garantía contenida en la Carta Fianza N° 216301224-R31 deberá ser devuelta.

2.11. En este sentido, se tiene que ante la existencia de saldo a favor del CONSORCIO (que en el presente caso es de muy probable concretización) la garantía de fiel cumplimiento (que en este caso es la Carta Fianza N° 216301224-R31), debe ser devuelta al CONSORCIO.

Sin embargo, <u>mientras no se practique la liquidación de la obra, la Carta Fianza N° 216301224-R31 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato debe mantenerse vigente</u>. Esto, refuerza los fundamentos del pedido cautelar, pues lo que se pide es una medida cautelar de no innovar, con la finalidad de mantener el status de hecho y de derecho; esto es, que no se ejecute la Carta Fianza N° 216301224-R31.

2.12. Adicionalmente, se debe precisar que, en una futura liquidación de la obra, se tiene (en alto grado de probabilidad) la existencia de saldo a favor del CONTRATISTA, por se encuentra pendiente el pago de la Valorización N° 18 de mayores metrados de la obra, y el pago del reajuste de la Valorización principal, que en conjunto ascienden a la suma de S/. 475,248.94 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho con 94/100 soles).

3. VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO

3.1. En el escrito de petición cautelar se ha expuesto la verosimilitud del derecho que se invoca. Sin embargo, siendo que en el presente escrito se ha señala nuevas pretensiones que serán parte del proceso principal, es necesario establecer la verosimilitud del derecho que se invoca.

Como se ha señalado, el CONSORCIO tienen saldo a su favor o deudas que aún no fueron pagas por la ENTIDAD, por lo que, en una futura liquidación de la obra le corresponderá el pago de la Valorización N° 18 de mayores metrados de la obra, y el pago del reajuste de la Valorización principal, que asciende a la suma de S/. 475,248.94 (cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho con 94/100 soles).

Es precisamente este derecho el que se pretende cautelar mediante la no innovación de la situación de hecho y de derecho de la Carta Fianza N° 216301224-R31.

*3.2. Este derecho, no solamente es verosímil, además, es parte de un mandato legal contenido en el artículo 126° del RLCE que establece "(…) En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista, **la Entidad debe devolver la garantía de fiel cumplimiento**, aun cuando se someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor." [Lo resaltado es nuestro]*

Por lo tanto, el derecho que se invoca (esto es, el pago de las valorizaciones) es un derecho verosímil, y será parte de una futura decisión arbitral contenida en el futuro laudo; por lo que, se debe cautelar su concreción y evitar que el derecho tutelado se torne en ilusorio.

<u>Sexto:</u> Que, la posición de la Municipalidad es la siguiente:

- **Escrito del 26 de octubre de 2022**

I. PETITORIO:

Que, dentro del término concedido, atendiendo a la Resolución Cautelar N° 01, acudimos a vuestro tribunal, con la finalidad de **emitir pronunciamiento con relación a lo solicitado**, en base a los siguientes fundamentos:

1. **Se declare improcedente la medida cautelar, en aplicación de la teoría de los hechos cumplidos**, de conformidad a la fundamentación en el apartado correspondiente.

2. **Se declare infundada la solicitud cautelar, por no acreditar el requisito de verosimilitud o apariencia en el derecho**, conforme a lo que se expondrá más adelante.

II. Sobre la improcedencia de la solicitud cautelar:

2.1. En efecto, por mandato constitucional se tiene el principio de irretroactividad de la norma; esto es, resulta inaplicable la norma cuya vigencia sobreviene a la existencia anterior de las relaciones bilaterales; en tanto, importa que las leyes se dictan para prever situaciones futuras, pero no para imponer a hechos ya producidos efectos distintos de aquellos que fueron previsibles dentro del orden jurídico existente en el momento de producirse, a ello se le denomina teoría de los hechos cumplidos.

2.2. Dentro del señalado contexto, el convenio arbitral establecido entre mi representada y el CONSORCIO ARES, ha sido suscrito con fecha 27 de setiembre de 2016; de otro lado, el Reglamento del Centro de Arbitraje a cuyos lineamientos se pretende sujetar el solicitante CONSORCIO ARES, corresponde a una fecha posterior; habida cuenta que, del Registro Nacional

de Árbitros y Centros de Arbitraje del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se tiene registrado el Centro con fecha 04 de febrero de 2022.

2.3. En consecuencia, no es posible que por aplicación de los lineamientos del citado Reglamento se pretenda someter a competencia del arbitraje de emergencia una relación bilateral que preexistía antes de su entrada en vigencia; por lo que, debe declararse la improcedencia del arbitraje de emergencia y la solicitud cautelar.

III. Sobre la carencia de requisito de verosimilitud o apariencia en el derecho:

3.1. Se precisa que la controversia puesta en conocimiento a vuestra instancia de emergencia ya ha sido sometida al proceso arbitral bajo la dirección de la CORTE SUPERIOR DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AYACUCHO, conforme a la resolución adjunta.

El citado proceso arbitral fue objeto de conclusión de actuaciones arbitrales con fecha 25 de julio del 2022. Así, aun cuando los plazos para el consentimiento de la resolución de contrato se hayan renovado, la caducidad ha operado de conformidad a la normativa de contrataciones del Estado aplicable.

Javier Contreras De La Cruz
ALCALDE

3.2. Siendo ello así, no existe apariencia en el derecho que revista de tutela urgente; por cuanto el CONSORCIO solicitante ha tenido oportunidad de poder realizar cuanta acción considere conveniente a sus intereses, en el decurso del mencionado proceso arbitral.

3.3. La solicitud cautelar formulada por el CONSORCIO ARES obedece tan solamente a la desesperanza causada por los efectos de su inercia al haber permitido llegar al estadío en el que nos encontramos, y que mi representada en ejercicio legítimo de sus derechos por ser parte perjudicada con la resolución de contrato haga efectivo la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

3.4. Estando a ello, es pasible de que vuestro despacho declare infundado la solicitud cautelar; lo contrario sería rebasar los límites que tiene como autoridad en el presente mecanismo de solución de controversias.

- **Escrito del 3 de noviembre de 2022**

Que, dentro del término concedido, atendiendo a la Resolución Cautelar N° 02, acudimos a vuestro tribunal, con la finalidad de **emitir pronunciamiento con relación a lo solicitado**, en base a los siguientes fundamentos:

1. **Reiteramos nuestro pedido de que se declare improcedente o infundada la solicitud cautelar; en base a lo siguiente:**

   1.1. El solicitante, pretende confundir a vuestro tribunal al incrementar sus fundamentos y pretensiones a someterse en un eventual proceso arbitral; pues el único hecho en controversia y per se debe ser objeto de evaluación es que; la Entidad frente al incumplimiento de obligaciones contractuales del CONSORCIO ARES, previo requerimiento de conformidad a la normativa de contrataciones del Estado, ha adoptado la determinación de resolver el contrato como consecuencia de dicho incumplimiento.

   1.2. Situación materializada mediante Carta Notarial de fecha 15 de setiembre de 2020, constituida por la Resolución de Alcaldía N° 188-2020-MDASF/A de 14 de setiembre de 2020; esto es, a partir de ello el contratista al verse afectado activa los mecanismos de solución de controversias **dentro del plazo de caducidad**. Lo que ocurrió ya en un proceso arbitral ante la CORTE SUPERIOR DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AYACUCHO; empero que, se dio por concluida las actuaciones arbitrales con fecha 25 de julio del 2022.

   Lo que significa que la caducidad ha operado por haber transcurrido el plazo de ley.

1.3. De otro lado, respecto de la liquidación de un contrato de obra que ha sido resuelto, podían advertirse dos posibles situaciones: (i) que la resolución del contrato hubiese quedado consentida debido a que ninguna de las partes la sometió a conciliación o arbitraje, escenario en el que debía procederse con la liquidación del contrato de obra; o (ii) que la resolución del contrato hubiese sido sometida a conciliación o arbitraje dentro del plazo previsto, escenario en el que, no podía procederse a realizar la liquidación del contrato de obra, puesto que existiría una controversia anterior a la liquidación pendiente por resolver.

En esa línea, mal hace el CONSORCIO ARES, alegando que la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento está condicionada a la liquidación de obra; dado que, el hecho de que el acto mediante el cual se resolvió el contrato ha quedado consentido habilita a la Entidad a tomar las acciones subsiguientes por consecuencia del incumplimiento de obligaciones de parte del contratista, como viene a ser la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

1.4. Siendo ello así, REITERAMOS QUE no existe apariencia en el derecho que revista de tutela urgente; por cuanto el CONSORCIO solicitante ha tenido oportunidad de poder realizar cuanta acción considere conveniente a sus intereses, en el decurso del mencionado proceso arbitral.

<u>Sétimo</u>: La posición del Árbitro Único – Marco Teórico.

1. La Medida Cautelar debe ser adecuada a la naturaleza de la pretensión, también debe estar premunida de razonabilidad y utilidad, pues la actividad cautelar responde al principio de la mínima injerencia, que impone evitar los perjuicios innecesarios al presunto deudor u obligado; de ahí que, una de las reglas a considerar en la cautela debe ser que el acreedor no puede exigir que la resolución cautelar recaiga y/o afecte bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiera otros disponibles. En suma, a través de esto se busca crear un equilibrio entre el interés del acreedor con la cautela y los efectos de esta afectación frente al presunto deudor; esta ponderación se realiza en búsqueda del equilibrio, lleva trabajar la idea de proporcionalidad entre la magnitud de la afectación con la cobertura del derecho que se quiere asegurar.

2. Por otra parte, es preciso señalar que, para otorgar una medida cautelar, la parte que lo solicita debe demostrar: ***(i)*** la apariencia del derecho invocado ó ***"fumus boni iuris"***, ***(ii)*** un real peligro de irreparabilidad en la demora o ***"periculum in mora"*** y; ***(iii)*** la adecuación del pedido cautelar. Que, sobre la Verosimilitud del derecho, debemos considerar a lo aparente, es decir, a la probable existencia de un derecho, del cual se pide o se pedirá, tutela en el proceso principal. Para esto, señala Liebman[5], no se trata de establecer la certeza de la existencia del derecho, que es propiamente el objeto del proceso principal, sino de formular un juicio de probabilidad de su existencia sobre la base de una cognición sumaria y superficial, - prima facie - ya que el análisis detenido y riguroso se realizará al interior del proceso principal en el cual las partes ejercitaran sus derechos en los estadios correspondientes.

3. Asimismo, y no obstante lo antes expresado, pese al examen prima facie, debe tenerse en cuenta que, para el caso de medidas cautelares emitidas por los árbitros, generalmente, la parte contraria a la solicitante es informada y consultada acerca de la medida cautelar solicitada por lo que el grado de cognición de los árbitros de los hechos y términos de la pretensión cautelar son percibidos desde los dos puntos de vista que se presentan en la contienda arbitral, sin que eso signifique que el análisis tenga un carácter distinto al que produce un análisis prima facie. En esa misma línea, la verosimilitud del derecho invocado no supone un convencimiento pleno o certeza del juzgador de lo alegado sino, simplemente –de acuerdo con la Doctrina autorizada-, que tenga una apariencia de verdadero o, como dice, Piero Calamandrei, una "*hipótesis*" razonable, sujeta al examen y decisión que deberá tomar el árbitro en el laudo, el conocimiento sumario de los hechos y de las causas que motivan el pedido cautelar que de modo solvente sustente dicho pedido. Asimismo, lo verosímil ha de ser el derecho, que el invocado por quien pide la medida, aparezca a la luz de la razón como posiblemente cierto, es decir, conllevando por su contundencia, la virtud de ser reconocido por un juicio de certeza si se confirman durante el pleito los elementos que se observan al tiempo de formular el juicio de verosimilitud.

[5] **LIEBMAN Enrico (1980)** *Manual de Derecho Procesal Civil*, Ediciones Jurídicas Europa –América, Buenos Aires, Pág. 162.

4. Que, en consecuencia, como dicen algunos autores, esa verosimilitud consiste en un ***"fumus iuris boni"***, un mero "*humo de buen derecho*", en otras palabras, que la demanda debe tener un viso de razonabilidad, aunque sea tenue y evanescente como el humo; es decir, lo que se exige es que, no se pueda considerarse a los solicitado, prima facie, como un pedido estrafalario o absolutamente ajeno a Derecho. En otras palabras, lo posible es lo que, es admitido como susceptible de darse en la realidad; el derecho será verosímil si es probable que exista, y lo probable es lo que se puede demostrar mediante a comprobación de los hechos. En cuanto al peligro en la ***demora "Periculum in mora"*** constituye un elemento importante a tomar en cuenta en el estudio de la medida cautelar. Vale decir, requiere ser alegado y justificado, más no probado. Al respecto, Barrios De Angelis, citado por Ledesma Narváez ([6]), advierte que, todo el fenómeno no determina un peligro actual para que el objeto del proceso se modifique, por causa externa o interna, antes de que las funciones principales se hallen en estado de transformarlo; o que el peligro actual vierta sobre la alteración de los medios de instrucción, por causa interna sumada a la falta de instantaneidad del proceso. En ambos casos se tiene en cuenta el daño previsible para la plena eficacia de las funciones ejercidas en el futuro. Ahora bien, Liebman, indica que para innovar el peligro basta señalar un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, lleguen a faltar o alterar las circunstancias de hecho favorables a la tutela misma, esto implicada que el peligro en el demora habrá de ser apreciado con relación a la urgencia en obtener protección especial, dados los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar al dictado del laudo; de allí que, la medida cautelar no solo busque garantizar sino anticipar los efectos de dicho fallo.

5. En ese sentido, la posibilidad de peligro señalada por el Consorcio es igualmente verosímil en el sentido antes indicado de esta palabra, puesto que el no ampararla podría provocar un daño que finalmente pueda impedir los efectos de la conclusión final del Laudo. Que, por otro lado, no puede exigirse una interpretación restrictiva de los hechos y del derecho en la concesión de medidas cautelares porque, ello sería contrario a la idea de apariencia o "humo" que prima en la naturaleza de esta institución y, por ese camino, atentaría

[6] **LEDESMA NARVAEZ, Marianella**, *Comentarios al Código Procesal Civil*, *Tomo III*, Ed. Gaceta Jurídica, Pág. 28.

contra el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que la función de solución de conflictos quedaría desnaturalizada si los laudos no pueden hacerse efectivos en la práctica. Que, en atención a lo anterior, en casos de duda debe resolverse a favor de la concesión de la medida cautelar, teniendo en cuenta que, a opinión de este colegiado, debido a la naturaleza variable de las medidas cautelares, éstas siempre pueden ser sustituidas y/o modificadas cuando el afectado ofrezca garantía suficiente.

Séptimo: Posición del Árbitro Único ante los argumentos de las partes.

A) Apariencia de derecho:

6. En cuanto a la apariencia de derecho, se identifica que la Litis (en base a las pretensiones de la futura demanda) se compone y desarrolla en dos aspectos marcados estos son: la resolución contractual determinada por la Municipalidad, a través de la cual manifestó su voluntad de dar por concluido el contrato; y el otro aspecto, se refiere a pagos de una valorización y de un reajuste.

7. Cabe precisar que después de la resolución de la Entidad, sucedieron hechos conforme han sido narrados por las partes (donde se incluye el inicio de un arbitraje anterior para discutir la resolución de contrato, pero que concluyo sin pronunciamiento sobre el fondo por falta de pago de los gastos arbitrales) y citados en la parte expositiva de esta resolución, con consecuencias jurídicas que pondrían en situación de acreedor al Consorcio frente a la Municipalidad bajo la base de las consecuencias causadas por la decisión de dejar sin efecto el contrato invocado por la Entidad, además de los conceptos que se reclaman por los pagos que el Consorcio considera tiene derecho.

8. Por su parte la Municipalidad, alude fundamentalmente a indicar que el derecho del Consorcio a controvertir (arbitrar) l resolución de contrato efectuada por la Entidad ha caducado como efecto de la conclusión sin pronunciamiento sobre el fondo del arbitraje anterior.

9. El Árbitro Único estima que la apariencia de derecho se sostiene medularmente en los hechos citados pues no es pacífico en la doctrina y tampoco en los laudos emitidos en la materia que si se inició un arbitraje antes que opere el plazo de caducidad y este concluye por falta de pago de los gastos arbitrales (sin

pronunciamiento sobre el fondo), ello implique el plazo de caducidad se reactive o si quiera si existe aún un plazo de caducidad, lo cual deberá de ser analizado y resuelto por el árbitr o los árbitros que conozca el fondo de la controversia; en ese sentido, para este Árbitro Único es real y concreto que de lo argumentado por el Consorcio se configura el *fumus bonnus juris* que se requiere, pues su derecho es posible o probable.

B) <u>Peligro en la demora</u>:

10. Para analizar la concurrencia del presupuesto de ***"peligro en la demora"***, el Árbitro Único considerar pertinente analizar cual es la posición del solicitante frente a los hechos cuya cautela solicita sea otorgada, se sostiene que el peligro en la demora se configura por el hecho objetivo e inminente de que el efecto de la ejecución de las fianzas de fiel cumplimiento en el Consorcio significa soportar una sanción desde antes que se haya determinado si existió o no existió base para su ejecución, afectando de esta forma a las personas (jurídicas y/o naturales) que conforman el Consorcio con la disminución de sus patrimonios durante la secuela del proceso arbitral.

11. Para el Árbitro Único, la afectación al patrimonio es un hecho positivo, evidenciado en la posible ejecución de la fianza de fiel cumplimiento y como se ha señalado considera que basta señalar un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, siendo en el presente caso que habiéndose abierto la discusión con este proceso acerca de la validez de los actos de la Municipalidad en la resolución de contrato que ha efectuado, lo cual le daría derecho a la ejecución de la fianza, la parte peticionante podría sufrir el efecto como si su derecho hubiese sido desestimado, agravándose su posición financiera al no contar con los fondos que representa el monto de las cartas fianzas.

C) <u>Adecuación de la medida cautelar:</u>

12. El Árbitro Único tiene la facultad de graduar la intensidad del efecto de la medida cautelar, a decir de la doctrina ([7]) *"la alteración de la relación material es una necesidad – en muchos casos- para que la*

[7] **Monroy Palacios, Juan José**. *Bases para la formación de una Teoría Cautelar*. Edit. Comunidad 2002. Pag.187-188.

medida cautelar cumpla su finalidad. Sin embargo, esta realidad tiene que ser conjugada con el hecho que el juez debe otorgar aquella medida que afecte lo menos posible los intereses del sujeto sobre quien recae la misma" y para el efecto aplicar el principio de mínima injerencia.

13. Es por ello que estando a que la pretensión cautelar persigue que evite la ejecución de la garantía sobre las obligaciones de fiel cumplimiento contenidas en el contrato se mantengan hasta la decisión final que se emita con el laudo arbitral, el Árbitro estima que el propósito es mantener el estadio que evidencia un equilibrio de la relación contractual afectada por una disputa, para que luego de resuelta esta se pueda proceder a accionar sobre ellas sobre la base del nuevo orden jurídico que instaure el laudo arbitral. Siendo ello el propósito, para el Árbitro resulta adecuado establecer los mecanismos que no puedan alterar los derechos de las partes y en particular de la Entidad, dentro del contexto del proceso arbitral y la determinación de solución de la disputa planteada y que si bien una medida cautelar tiene un efecto directo en la esfera jurídica de quien la padece, esta no afecte de modo que lo ponga en una situación gravosa que desestabilice su posición.

Octavo: En cuanto a la ***caución de la media cautelar*** el Árbitro señala:

14. Primero que, conviene en primer lugar tratar el punto de lo regulado por el Decreto de Urgencia N° 20 – 2020 modificatorio del Decreto Legislativo 1071 que norma el arbitraje y que dispone, que cuando el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contra cautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, no pudiendo ser el monto de la caución, menor a la garantía de fiel cumplimiento del contrato (disposición normativa similar se ha establecido en la Ley N° 31589).

15. Ante la premisa planteada el Árbitro Único advierte que, estamos frente una norma que establece una condición diferenciada exorbitante respecto de los demás usuarios del arbitraje y que, por lo tanto, colisiona con el ordenamiento legal de tutela. Ante ello es preciso considerar el ejercicio del control difuso, sistema de control constitucional jurisdiccional mediante el cual los jueces tienen la

facultad de inaplicar una norma de inferior jerarquía ante su incompatibilidad con el texto constitucional.

16. En efecto, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional desarrolla meridianamente el control difuso e interpretación constitucional. En el caso, el solicitante de la medida cautelar ha indicado que debe aplicarse el control difuso por ser el Decreto en cuestión inconstitucional pues este vulneraría los derechos fundamentales de igualdad, tutela jurisdiccional efectiva y el principio de razonabilidad.

17. Ante lo expuesto el Árbitro, de acuerdo a doctrina autorizada y a los precedentes existentes del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad que en sede jurisdiccional arbitral se ejerza control difuso de constitucionalidad de las normas, se avoca al examen de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N° 20 – 2020 en el extremo correspondiente. ([8])

18. En el orden expuesto cabe ahora señalar que, los árbitros pueden ejercer el control difuso**,** entendido como el poder-deber de inaplicar una norma legal contraria a la Constitución, teniendo como fundamento los principios de independencia y unidad de la función jurisdiccional**.** Esto, como lo expresa el propio Tribunal Constitucional, no implica que la administración de justicia sea exclusiva del Poder Judicial, pues dicha facultad, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la ejercen también los árbitros, de manera que los órganos que administren justicia, sin excepción, posean las garantías propias de todo órgano jurisdiccional.

19. Pues bien, en efecto, las exigencias diferentes y más gravosas que exige el Decreto en cuestión a los particulares en los procesos arbitrales con el Estado en comparación de las garantías aplicables a las medidas cautelares en los procesos arbitrales entre particulares, todo ello sin que exista argumento razonable para esa diferenciación, contraviene en efecto el principio de igualdad ([9]). Si

[8] El Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca de la facultad de los árbitros para aplicar el control difuso y se advierte ello de Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. 00142-2011-PA/TC, Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Sociedad Minera de Responsabilidad Ltda. María Julia contra la resolución expedida por la tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

[9] El artículo 2 de la Constitución consagra el principio de igual ante la ley y así lo reconoce la STC N° 02835-2010-PA/TC, en una de sus considerandos estima que "[...] toda persona tiene derecho [...] a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole"

bien es innegable que, en contratación pública existe un régimen legal exorbitante para los particulares contratistas del Estado en atención a los intereses públicos a los que se debe el Estado y que están contenidos en la Ley, debe decirse que este régimen legal expreso de prerrogativas públicas debe estar limitado, en primer lugar, por sistematización y especialización, a la Ley de Contrataciones del Estado misma o su Reglamento y no estar contenido en el régimen general de arbitraje; pero, además y sobre todo, esas ventajas públicas deben limitarse a la fase de ejecución de los contratos y no al régimen procesal de la solución de controversias que impone un tratamiento igualitario a las partes que contienden en un proceso, no existiendo razones legales suficientes para ello expresadas en el Decreto de Urgencia en cuestión y que puedan contradecir ni justificar el dispositivo del citado.

20. No deben ser admisibles ventajas públicas procesales capitales y exorbitantes que limiten los derechos de la parte privada sin ninguna justificación válida, más aún si existen ya disposiciones procesales de por si inequitativas en torno a los embargos contra el Estado o a procedimientos específicos de ejecución de laudos sujetos a disponibilidad presupuestal.

21. Por otro lado, la exposición de motivos del Decreto de Urgencia que alude a abusos en la admisión de cauciones juratorias como garantías de posibles daños causados por medidas cautelares otorgadas a los particulares en las controversias provenientes de contratos estatales, así como la disposición misma de exigirse una caución del 10% del contrato como mínimo, conlleva una restricción sustancial de la garantía constitucional a una debida tutela jurisdiccional exorbitando en grado tal el régimen - comparándolo con los arbitrajes en donde no interviene el Estado y, también, con las controversias en sede judicial - , que en muchos casos sería altamente desproporcionado e irracional que los particulares asuman dicha garantía, como puede ser el caso, por ejemplo de una medida cautelar respecto de la indebida ejecución de penalidades de montos muy menores respecto de la contra cautela o sino si se requiere por ejemplo una medida cautelar sobre la ejecución indebida de una garantía de fiel cumplimiento cuyo monto alcanza precisamente el 10% del monto del contrato, como es el caso.

22. En la práctica, sin que exista análisis del juzgador respecto del caso, se exigirá universalmente una garantía que en algunos casos alcanza

el equivalente al 100% del monto de la medida cautelar (el monto de la garantía es del 10% del contrato y el de la caución mínima también) y en otra puede fácilmente superar varias veces el monto de lo reclamado.

23. En el presente caso la medida cautelar solicitada está referida a la no ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, por lo que resultaría desproporcional y contraria al principio de razonabilidad si se exigiera para ello un monto equivalente al 10% del contrato. Resulta evidente que, la exigencia de una contracautela equivalente al 100% de la garantía de fiel cumplimiento, hace notoria la desigualdad de trato contenido en el Decreto de Urgencia, e impactaría directamente en contra del derecho de tutela jurisdiccional que se ha solicitado.

24. Asimismo, debe considerarse que el Árbitro Único no observa la necesidad de que se constituya de una contracautela, toda vez que para ello ya se cuenta con la carta fianza de fiel cumplimiento. En ese sentido, resulta suficiente que se requiera una caución juratoria.

Noveno: En conclusión el Árbitro Único considera que, en el presente caso y sin que ello implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto, dada la naturaleza temporal y variable de la decisión cautelar, (a) la pretensión del Consorcio tiene apariencia de derecho y no puede ser descalificada de plano por falta de fundamento alguno y (b) el peligro que se indica es también verosímil, sin que ello implique la certeza de que se produzca, puesto que podría presentarse un real peligro de no amparar la pretensión en cuestión, antes de que se expida el correspondiente laudo arbitral. Que, en estas circunstancias, si el Árbitro Único no concede la medida cautelar solicitada, existe la posibilidad de que, si el laudo es favorable al Consorcio, éste no pueda ser hecho efectivo en la realidad, debido a que por la demora en el proceso el daño hipotético podría convertirse en real e irreparable.

Que, por estas razones, el Árbitro Único considera que se le debe conceder al Consorcio la **medida cautelar solicitada en los términos que se mencionan en la parte resolutiva.** -

En ese sentido y por las consideraciones antes expuestas el Árbitro Único **RESUELVE:**

Primero. - CONCÉDASE LA MEDIDA CAUTELAR, conforme a las siguientes instrucciones:

A) **Dispóngase** que la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco se encuentra impedida de ejecutar la **CARTA FIANZA N° 216301224-R31**, emitida por INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, por el importe de S/. 1´313,323.25 (un millón trecientos trece mil trecientos veintitrés con 25/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N° 091-2016-MDASF/ULCP.

B) **Dispóngase** que el Consorcio Ares mantenga la vigencia de la **CARTA FIANZA N° 216301224-R31**, debiendo informar de su renovación a la Entidad previamente a su vencimiento, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, la medida cautelar se considere automáticamente levantada.

C) **Dispóngase** que el Consorcio Ares cumpla con presentar una caución juratoria por el monto de la **CARTA FIANZA N° 216301224-R31** con firma de su representante legalizada notarialmente en un plazo de tres (3) días hábiles de notificada la presente medida cautelar, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, la medida cautelar se considere automáticamente levantada.

D) **Dispóngase** que la presente resolución se notifique a INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Segundo: **NOTIFÍQUESE** a las partes y a INSUR.

LUIS PUGLIANINI GUERRA
ÁRBITRO ÚNICO

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI
SECRETARIA ARBITRAL

EXP. N° 17-2022-LPG-CA-CECARD/AYA

Ayacucho, 11 de noviembre del 2022.

DEMANDANTE: **CONSORCIO ARES**
DEMANDADO: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO**

RESOLUCIÓN CAUTELAR N° 05

VISTO: Escrito N° 03 de fecha 10 de noviembre de 2022, con sumilla "Cumplo con presentar caución juratoria", presentado por el CONSORCIO ARES (en adelante el **CONSORCIO**).

CONSIDERANDO:

1. A través de la Resolución Nro. 04 de fecha 07 de noviembre de 2022, el Árbitro de emergencia resolvió el pedido de medida cautelar solicitado por el Consorcio Ares, en ese sentido se dispuso entre otros otorgar al Consorcio el plazo de tres (03) días hábiles a fin de que presente una caución juratoria por el monto de la Carta Fianza N° 216301224-R31 con firma legalizada notarialmente.

2. En esa línea, mediante escrito de visto y dentro del plazo otorgado, el Consorcio remite la caución juratoria ordenada, cumpliendo con ello el mandado ordenado por el Árbitro de emergencia, la misma que debe tenerse por complido con conocimiento de su contraparte.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral **RESUELVE:**

PRIMERO: TÉNGASE por presentado la caución juratoria efectuado por el Consorcio Ares, debiéndose tener por cumplido el requerimiento con conocimiento de la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco.

SEGUNDO: DÉJESE CONSTANCIA, que la medida cautelar ordenada es temporal, pudiendo el Árbitro que conozca el proceso principal dejarla sin efecto en caso alguna de las partes solicite su pronunciamiento en la etapa correspondiente.

LUIS PUGLIANINI GUERRA
ÁRBITRO ÚNICO

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI
SECRETARIA ARBITRAL